



ANALISTA
DIREITO PENAL
SILVIO MACIEL
AULA 9

ROTEIRO DE AULA

Sumário

Tema: TEORIA DA PENA

4- penas privativas de liberdade

Tema: PUNIBILIDADE

1. conceito
2. causas extintivas de punibilidade
3. efeitos das causas extintivas de punibilidade
4. causas extintivas de punibilidade previstas no art. 107 do cp
- 4.1 - Prescrição

4.7.3. Etapas na aplicação da pena

1ª Etapa: juiz fixa a quantidade de pena aplicada.

Existem 2 critérios: a) critério bifásico (Roberto Lyra, Frederico Marques e Basileu Garcia); b) critério trifásico (Nelson Hungria) que é o adotado pelo artigo 68 do CP.

Atenção: na pena de multa é adotado o critério bifásico (número de dias multa e valor de cada dia-multa)

Obs.: Alberto Silva Franco menciona uma quarta fase que é a substituição da prisão pela pena restritiva de direitos ou pecuniária.

Usando o critério trifásico do artigo 68 do CP.

- a) Pena-base (art. 59 do CP)
- b) Agravantes e atenuantes (artigos 61 a 65 do CP)
- c) Causas gerais e especiais de aumento e diminuição de pena

2ª Etapa : Juiz fixa o regime inicial prisional (art. 33 do CP)

3ª Etapa : Juiz verifica a possibilidade de:

- a) Substituir a prisão por apenas restritivas de direitos e/ou pena de multa
- b) Suspende a execução da pena de prisão (*sursis*)

Obs.: O juiz ainda decidirá na sentença sobre a aplicação dos efeitos penais e extrapenais da condenação e sobre a manutenção ou revogação da prisão preventiva .

1ª Etapa: juiz fixa a quantidade de pena aplicada usando o critério trifásico do artigo 68 do CP.

b) Agravantes e atenuantes

b.2.) Atenuantes

Vamos destacar algumas atenuantes:

b.2.1) Ser o agente menor de 21 na data do fato ou maior de 70 na data da sentença

Essa atenuante não foi tacitamente revogada pelo Código Civil que reduziu a maioridade absoluta para 18 anos. Ela também não se aplica a todo e qualquer idoso, mas apenas ao idoso maior de 70 anos, não tendo sido modificada pelo Estatuto do Idoso.

A idade de 70 anos deve ser verificada na data da publicação da sentença. Se o réu for absolvido e depois condenado pelo tribunal em recurso da acusação deve ser considerada a idade na data da sessão de julgamento.

STJ: “Sendo opostos embargos de declaração contra a sentença condenatória, e entre a sentença condenatória e o julgamento dos embargos o réu atinge a idade superior a 70 anos, é possível aplicar o art. 115 do Código Penal, tendo em vista que a decisão que julga os embargos integra a própria sentença condenatória” (EDcl no AgRg no REsp 1.877.388-CE, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, por unanimidade, julgado em 2/5/2023).

b.2.2.) Desconhecimento da lei

Aqui, o agente sabe da proibição, mas não sabe que há um dispositivo legal tratando disso [ex. pescador sabe da piracema e sua proibição de pesca, mas não sabe que há um crime ambiental]

Essa atenuante não pode ser confundida com a excludente de culpabilidade do erro de proibição inevitável [neste o agente não sabe e nem tem condições de saber que o que faz é proibido]

b.2.3.) Confissão espontânea

A confissão deve ser espontânea. Entretanto o STJ já decidiu que basta a voluntariedade (HC 117.764).

Para o STF e o STJ o simples reconhecimento da prática do crime enseja a atenuante uma vez que o código Penal não faz qualquer ressalva sobre a maneira como a gente pronuncia a confissão. Além disso trata-se de circunstância objetiva não sujeita ao subjetivismo do magistrado.

Aplica-se a atenuante mesmo que o juiz não tenha mencionado na sentença. *"Conforme recente entendimento desta Corte, o art. 65, III, 'd', do CP não exige, para sua incidência, que a confissão do réu tenha sido empregada na sentença como uma das razões da condenação, sendo que o direito subjetivo à atenuação da pena surge quando o agente confessa e não quando o juiz cita sua confissão na fundamentação da sentença condenatória"* (AgRg no AREsp n. 2.115.949/MG, DJe de 14/12/2022). (AgRg no REsp 1977941 / MA, 10.03.23)

Tema 1194 com a seguinte controvérsia: *Delimitação da controvérsia: Saber se eventual confissão do réu, não utilizada para a formação do convencimento do julgador, autoriza o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal*".

"1. A atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido retratação, exceto, neste último caso, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos. 2. A atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade."

Aplica-se atenuante ainda que existam outras provas para a condenação do réu.

No concurso de pessoas se o réu confessa o crime e isenta o comparsa aplica-se a atenuante (STJ, AgRg no Ag no Resp 1.726.860, 2020).

A confissão pode ser parcial, pois não precisa alcançar qualificadoras e causas de aumento de pena (STJ, HC 328.021)

Atenção - reinterpretar conforme tema acima: O fundamento da atenuante é a lealdade processual (STF, HC 101.909). Logo não se aplica a atenuante se o réu confessa na fase inquisitiva e se retrata em juízo. Entretanto subsiste a atenuante se a confissão do réu na fase inquisitiva, em conjunto com as demais provas do contraditório, serviu de fundamento para a condenação (STF, HC 91.654).

Súmula 545 do STJ: “quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus a atenuante prevista no artigo 65, III, d, do CP”. E ainda:

“Consoante entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, nos casos em que a confissão do acusado servir como um dos fundamentos para a condenação, deve ser aplicada a atenuante em questão, pouco importando se a confissão foi espontânea ou não, se foi total ou parcial, ou mesmo se foi realizada só na fase policial, com posterior retratação em juízo”. (REsp 1903295/SP, 06.03.2023)

A confissão qualificada configura atenuante de pena? Confissão qualificada é aquela na qual o réu admite o fato, mas alega excludente de ilicitude ou de culpabilidade.

STJ: *“Esta 5ª Turma, no julgamento do REsp n. 1.972.098/SC, em 20/6/2022, em conformidade com a Súmula n. 545/STJ, consignou que o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada”* (AgRg na PET no AREsp 2139652 / SP, 24.04.23). E AgRg no AREsp 2101541/GO (6ªT, 20.03.23)

STF: *“A confissão qualificada, segundo consolidada jurisprudência desta Suprema Corte, não enseja a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “d” do CP. Precedentes”*. (HC 206827, 18.04.2022)

Súmula 630 do STJ: “A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”.

A prisão em flagrante não impede o reconhecimento da atenuante.

Existem ainda as atenuantes inominadas (art. 66 do CP), que pode ser qualquer circunstância anterior, concomitante ou mesmo posterior ao crime. São atenuantes de clemência concedidas por bondade.

Coexistência de agravantes e atenuantes:

Regra: uma atenuante neutraliza uma agravante e vice-versa (regra da equivalência das circunstâncias)

Exceção: as agravantes e atenuantes relacionadas com os motivos determinantes do crime, com a personalidade do agente e com a reincidência preponderam sobre as demais (art. 68 CP).

Quando a maioridade civil iniciava-se aos 21 anos atenuante da menoridade relativa era a que mais preponderava sobre qualquer outra atenuante ou agravante. Esse entendimento perdeu o fundamento com a redução da maioridade civil para 18 anos.

Reincidência x confissão espontânea:

STJ: *"É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade". (TEMA 585, 22.06.22)*

STF: *"Não há ilegalidade na decisão que nega a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, uma vez que a reincidência é indicada pelo legislador como circunstância preponderante em caso de concurso de circunstâncias agravantes e atenuantes (art. 67 do Código Penal). Precedentes" (HC 227304 AgR, 16.06.2023)*

Bloco 2

c) Causas de aumento e de diminuição de pena

Incidem sobre a pena intermediária (pena-base + agravante e atenuantes) e não sobre a pena-base.

Podem reduzir ou aumentar a pena acima ou abaixo do mínimo previsto.

Se houver concurso de causas de aumento ou de diminuição aplica-se o artigo 68, parágrafo único, do CP: *"no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua"*. Temos então as seguintes situações:

- 1 – Duas ou mais causas de aumento ou diminuição previstas na parte geral do CP: devem ser aplicadas todas. O segundo aumento incide sobre a pena já aumentada pela primeira causa de aumento e não sobre a pena base ("juros sobre juros") e a segunda diminuição incide sobre a pena já diminuída pela primeira causa de diminuição, evitando-se a pena zero.
- 2 – Duas ou mais causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial do CP ou na legislação especial: o juiz pode aplicar um só aumento ou uma só diminuição, ainda que obrigatórias, limitando-se ao maior aumento ou a maior diminuição. Trata-se de faculdade do juiz e não de ato obrigatório.
- 3 – Uma causa de aumento e uma de diminuição: deverão ser simultaneamente aplicadas, desde que obrigatórias. O juiz primeiro aplica a causa de aumento e depois a de diminuição não podendo compensá-las.
- 4 – Duas causas de aumento ou de diminuição, uma na Parte Geral e outra na Parte Especial na Legislação Penal Especial: todas deverão ser aplicadas.

As causas de aumento remanescentes devem ser utilizadas como agravantes genéricas se previstas como tais ou residualmente como circunstâncias judiciais desfavoráveis. Já as causas de diminuição remanescentes deverão ser utilizadas como atenuantes genéricas nominadas ou inominadas.

A aplicação das causas de aumento e diminuição ensejará a pena definitiva.

2ª Etapa: Após aplicar a quantidade de pena o juiz fixará o regime inicial de cumprimento da pena.

O artigo 33 , § 1º do CP prevê 3 regimes de cumprimento de pena: fechado, semiaberto e aberto.

A determinação do regime inicial depende de 4 fatores: a) reincidência ; b) quantidade da pena ; c) circunstâncias judiciais; d) tipo de pena

A gravidade abstrata do crime não pode ser considerada na fixação do regime inicial (STJ).

O regime inicial é fixado em regra pelo juiz da condenação e excepcionalmente pelo juiz da execução quando durante o cumprimento da pena surgirem novas condenações transitadas em julgados caso em que deverá haver a soma das penas com a imposição do novo regime cabível.

O STF já declarou inconstitucional o regime inicial obrigatoriamente fechado nos crimes hediondos e assemelhados (HC 111.840), embora tenha reconhecido a constitucionalidade do regime inicial fechado nos crimes de tortura (HC 123.316).

O tráfico privilegiado não é delito equiparado hediondo podendo ser aplicado o regime aberto ou semiaberto .

Pena de reclusão:

Pode ser iniciada em quaisquer dos 3 regimes prisionais. As situações são as seguintes:

1ª) Reincidente: o regime inicial é o fechado independentemente da pena aplicada. A súmula 269 do STJ flexibiliza essa regra: “É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”

2ª) Primário: Pena superior a 8 anos regime fechado ; pena superior a 4 anos e não superior a 8 anos regime semiaberto; pena até 4 anos regime aberto .

O artigo 33 , § 3º do CP determina que o regime inicial levará em conta as circunstâncias judiciais (não somente a pena imposta). Assim sendo é possível ao juiz fixar regime inicial mais gravoso do que o permitido pela pena, desde que fundamentado nas circunstâncias judiciais desfavoráveis e não na gravidade abstrata do crime (Sumulas 718 e 719 do STF).

Pena de detenção :

Só pode ser iniciada nos regimes aberto ou semiaberto. É possível o regime fechado apenas no caso de regressão de regime.

As situações são as seguintes :

1ª) reincidente: inicia a pena no regime semiaberto independentemente da quantidade da pena aplicada ;

2ª) primário : regime semiaberto na pena superior a 4 anos em regime aberto na pena até 4 anos.

É possível o regime mais gravoso do que o determinado pela pena imposta desde que exista fundamentação idônea é baseada nas circunstâncias judiciais desfavoráveis. É o mesmo raciocínio aplicável à reclusão.

Diferenças entre reclusão e detenção:

São 4 diferenças fundamentais:

1ª) A reclusão pode ser cumprida inicialmente nos três regimes prisionais, enquanto a detenção somente pode ser iniciada nos regimes aberto e semiaberto.

2ª) No caso de aplicação cumulativa de reclusão e detenção executasse primeiro a reclusão.

3ª) A reclusão acarreta o efeito civil da incapacidade para o exercício do poder familiar, da tutela , ou da curatela os crimes dolosos cometidos contra o titular do poder familiar, ou contra o tutelado ou curatelado . esse efeito não existe na condenação à pena de detenção.

4ª) A reclusão acarreta internação como medida de segurança , enquanto a detenção acarreta tratamento ambulatorial .

3ª Etapa: O juiz verifica a possibilidade de substituir a prisão por a penas restritivas de direitos e/ou por multa ou de suspender a execução da pena de prisão (*sursis*).

a) Penas restritivas de direitos:

Estão previstas no rol exaustivo do artigo 43 do CP.

Não cabe ao réu escolher qual pena restritiva de direitos pretende cumprir em substituição a prisão tratando-se de ato discricionário do magistrado.

Características : as penas restritivas de direitos possuem duas características:

1 – substitutividade: As penas restritivas de direitos substituem as penas de prisão , não sendo penas principais .

2 – autonomia: Uma vez substituídas não podem ser cumuladas com a pena privativa de Liberdade e possuem regime de execução penal próprio .

Duração: tem a mesma duração da pena de prisão substituída. Exceção: a pena de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas superior a um ano pode ser cumprida em menor tempo desde que nunca inferior a metade da pena de prisão.

Obviamente que as penas de prestação pecuniária e de perda de bens e valores não seguem os mesmos prazos da pena de prisão porque possuem natureza patrimonial.

Requisitos: a substituição da pena de prisão por restritivas de direitos exige requisitos objetivos e subjetivos cumulativos.

Requisitos objetivos:

1 – *Crime doloso sem violência ou grave ameaça a pessoa* : se o crime é doloso a substituição só cabe nos delitos não violentos .

Para o STJ a substituição não cabe nem mesmo para aquele que teve participação de menor importância.

Prevalece o entendimento de que também não cabe a substituição no caso de violência imprópria (quando a vítima é reduzida à impossibilidade de resistência).

Prevalece o entendimento de que é cabível a substituição nas infrações de menor potencial ofensivo praticadas com violência ou grave ameaça.

É cabível a substituição em todos os crimes culposos uma vez que a violência não é intencional.

2 - *Quantidade de pena aplicada*

Nos crimes dolosos a substituição só é cabível nas condenações até 4 anos.

No caso de concurso de crimes deve-se levar em conta a pena total decorrente da soma ou da exasperação (STJ, HC 289.110)

Nos crimes culposos a substituição é cabível qualquer que seja a pena aplicada.

Exceções: homicídio culposos e lesão corporal culposa praticados na direção de veículo automotor em situação de embriaguez (art. 312-B da Lei 9.503/97)

Requisitos subjetivos:

1 – *Não reincidência em crime doloso*

Existe uma exceção: O juiz poderá permitir a substituição desde que em face da condenação anterior a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não seja na prática do mesmo crime.

A reincidência em crime culposos obviamente não impede a substituição.

2 – Circunstâncias judiciais favoráveis

A culpabilidade , os antecedentes , a conduta social , a personalidade do condenado, bem como os motivos e circunstâncias do crime indicarem que a substituição é suficiente (princípio da suficiência).

Por tal razão não cabe a substituição quando a pena-base é fixada acima do mínimo justamente em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis (STJ, HC 202.056, 19.09.2014)

Violência doméstica e familiar contra a mulher:

A Lei 11.340/06 não veda expressamente a substituição de prisão por penas restritivas de direitos, vedando apenas aplicação isolada de penas pecuniárias ou de multa.

STJ: Súmula 588 do STJ: *“a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de Liberdade por restritiva de direitos”*

“Não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos em crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A vedação abrange, inclusive, o delito previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, haja vista que um dos bens jurídicos tutelados é a integridade física e psíquica da mulher em favor de quem se fixaram medidas protetivas”. (AgRg no HC 735437 / PR, 10.06.22)

STF: também decidiu que não cabe penas restritivas de direitos nesses crimes (HC 129.446). O STF entende que não cabe a substituição por penas restritivas de direitos nem mesmo nas contravenções praticadas em situação de violência doméstica contra a mulher (HC 137.888).

Também não é cabível pena restritiva de direito nos crimes militares.

Competência para efetuar a substituição:

A substituição em regra deve ser feita pelo juiz da sentença.

Excepcionalmente pode ser feita pelo juiz da execução se:

- I – foi pena privativa de Liberdade não superior a 2 anos ;
- II – esteja sendo cumprida em regime aberto;
- III – tenha sido cumprido pelo menos 1/4 da pena;
- IV – Os antecedentes é personalidade e indiquem a substituição (art. 180 da LEP).

Bloco 3

Regras da substituição (art. 44, § 2º):

1 - Nas condenações até um ano a substituição pode ocorrer por uma multa *ou* uma pena restritiva de direitos, pouco importando se a condenação é por crime doloso ou culposo e se a pena é de reclusão ou de detenção .

Obs: Apesar do artigo 60 , § 2º do CP permitir a substituição por multa apenas nas condenações até 6 meses prevalece o entendimento de que a norma do artigo 44 , § 2º, I, é a que deve ser aplicada por ser mais favorável ao réu .

2 – Nas condenações superiores a 1 ano a prisão pode ser substituída por uma restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos que serão cumpridas, simultaneamente, se compatíveis entre si ou, sucessivamente, se não compatíveis entre si.

Conversão da pena restritiva de direitos em pena privativa de Liberdade:

A pena restritiva de direitos pode ser reconvertida em prisão em dois casos:

a) *Quando houver o descumprimento injustificado da restritiva.* Haverá detração do período já cumprido de pena respeitado um saldo mínimo de 30 dias. Obs.: No caso de prisão simples não é necessário o saldo mínimo. Essa reconversão é obrigatória.

Essa reconversão constitui incidente da execução penal e exige o contraditório e a ampla defesa, devendo o acusado ser intimado para justificar o descumprimento e só então , caso não ocorra justificação , realizar-se a reconversão (STJ, HC 251.312)

O STF entende que a mudança de domicílio sem comunicação ao juízo e que inviabiliza o cumprimento da pena executiva de direitos é motivo para a reconversão (STF, HC 92.012), Por violação à boa-fé objetiva.

Há entendimento de que o pagamento incompleto da prestação pecuniária também permite a reconversão respeitada a detração. Por exemplo, se o réu pagou apenas metade da prestação pecuniária imposta ela deve ser reconvertida em prisão com a detração de metade da pena.

O juiz não pode realizar a reconversão a pedido do réu porque este entende menos gravoso o cumprimento da prisão. A substituição é ato de jurisdição estatal que não está sujeita à vontade do condenado (STJ, Resp 1.524.484).

b) *Quando sobrevieram nova condenação a pena de prisão, por outro crime, o juiz da execução poderá realizar a reconversão, podendo deixar de fazê-la se for possível cumprir a pena restritiva e a pena de prisão.* Trata-se de reconversão facultativa.

Essa reconversão não pode ocorrer se houver nova condenação a pena de multa ou por contravenção penal uma vez que o CP exige que a nova condenação seja pela prática de crime e a pena seja de prisão.

Execução provisória: assim como não pode ser executada a pena de prisão antes do trânsito em julgado de condenação , também não pode ser executada a pena restritiva de direitos.

Sumula 643 do STJ: “a execução da pena restritiva de direitos depende do trânsito em julgado da condenação”.

Espécies de penas restritivas de direitos:

1 – Prestação pecuniária

Trata-se do pagamento em dinheiro no valor de 1 a 360 salários mínimos para a vítima, seus dependentes, ou entidade pública ou privada com destinação social, nessa ordem de preferência. Entretanto, havendo aceitação do beneficiário a prestação pode ser de outra natureza (art. 45, § 2º CP).

Trata-se de norma cogente que não depende da aceitação do destinatário da prestação.

O valor pago será deduzido de eventual condenação civil (ainda que decorrente de acordo homologado judicialmente) desde que o beneficiário seja o mesmo. A prestação pecuniária nesse caso é na verdade indenização civil antecipada, embora com a roupagem de pena restritiva de direitos.

É possível ainda ser deduzida do valor de reparação do dano fixado na própria sentença condenatória (art. 387, IV, CPP) (STJ, Resp 1.882.059, 2021)

A prestação pecuniária não se confunde com a pena de multa:

I - A prestação pecuniária pode ser reconvertida em prisão , a pena de multa não;

II - A prestação pecuniária destina-se à vítima , seus dependentes , ou entidades sociais , já a multa destina-se ao Estado;

III – A prestação pecuniária não é deduzida de condenação civil, já a multa pode ser.

2 – Perda de bens e valores

Essa pena recai sobre o patrimônio lícito do condenado.

O valor é fixado levando-se em conta o prejuízo causado para a vítima ou o proveito obtido pelo infrator ou por terceiros, o que for maior.

Tendo em vista o princípio da intranscendência da pena não pode se estender aos sucessores do condenado.

Tem nítido caráter confiscatório, sendo constitucional porque expressamente prevista o artigo 5º, XLVI, “b” da CF.

Não se confunde entretanto com o efeito da condenação que é o confisco de instrumentos ou produtos do crime (recai sobre o patrimônio ilícito do condenado).

3 – Prestação de serviços à comunidade

Somente é cabível nas condenações superiores a 6 meses.

As tarefas devem ser cumpridas em 1 hora por dia de condenação e de forma que não prejudique a jornada de trabalho (sistema da hora-tarefa).

Se a prestação de serviços for por prazo superior a um ano poderá ser cumprida em menor tempo nunca inferior à metade da pena de prisão substituída. Essa antecipação do cumprimento total da pena é uma opção do condenado, não podendo ser imposta pelo juiz.

A prestação de serviços à comunidade não é remunerada e não ocasiona vínculo empregatício com o Estado (LEP, artigos 28, § 2º e 30).

A prestação de serviços à comunidade não é inconstitucional porque não pode ser equiparada a pena de trabalhos forçados. Tem de ser pena previsto em norma constitucional originária trata-se de benefício ao condenado.

Se não houver local para o cumprimento da pena existem três soluções sugeridas:

1ª) a pena deve ser considerada como cumprida se decorrido o tempo dela no qual o condenado estava à disposição para cumpri-la;

2ª) deve-se aguardar o local adequado, salvo se antes ocorrer a prescrição;

3ª) o juiz deve buscar outro local adequado para o cumprimento. (STJ)

4 – Interdição temporária de direitos

Somente é cabível nos crimes cometidos no exercício da profissão, atividade, ofício, cargo ou função e sempre que houver violação dos deveres que lhe são inerentes.

Inclui a interdição temporária para o mandato eletivo, embora exista posicionamento de que essa pena é inconstitucional porque a CF só prevê a perda do mandato e não interdição temporária.

Essa pena não é cabível apenas nos crimes contra a administração pública, mas também nos crimes comuns.

A Lei 12.550/2011 incluiu dentre essas penas a proibição de inscrever-se em concurso, avaliação, ou exames públicos. E pode ser aplicada no caso de condenação por qualquer crime não apenas no crime do artigo 311-A.

5 – Limitação de fim de semana

Consiste na obrigação do condenado de permanecer aos sábados e domingos por 5 horas diárias em casa do albergado ou estabelecimento adequado. Pouco utilizada na prática tendo em vista a ausência desses estabelecimentos.

Bloco 4

b) Pena de multa

Critério de fixação: é o critério do dia-multa, calculado na forma do artigo 49 do CP.

O CP adota o critério bifásico na fixação da pena de multa (não o critério trifásico adotado na fixação das penas privativas de Liberdade):

1ª fase: o juiz estabelece o número de dias multa entre 10 e 360. Para chegar a esse valor o juiz leva em conta as circunstâncias judiciais, atenuantes e agravantes, causas de aumento e diminuição de pena.

2ª fase: o juiz fixa o valor de cada dia multa entre um 1/30 a 5 vezes o salário mínimo vigente na data da infração. Para definir o valor de cada dia multa o juiz leva em conta a situação econômica do réu.

A multa, ainda que aplicada no máximo, pode ser triplicada tendo em vista a situação econômica do condenado.

Multa irrisória: existem duas correntes quanto à obrigatoriedade ou não de sua cobrança:

1ª) A multa irrisória não deve ser executada porque o poder público gastará valor superior ao arrecadado;

2ª) a cobrança em juízo é obrigatória pouco importando o valor da multa tendo em vista os princípios da imperatividade e da inderrogabilidade da pena. É o entendimento predominante. A Portaria 75/2012 do Ministério da Fazenda que estabelece valor mínimo para execução da dívida ativa da União ressalva a pena de multa. (entendimento predominante)

Pagamento da multa: o pagamento voluntário deve ocorrer em até 10 dias após o trânsito em julgado da condenação. A LEP (art. 169) permite que o juiz parcele o pagamento, não estabelecendo o número máximo de parcelas. Pode ainda ocorrer desconto na remuneração do condenado quando for aplicado isoladamente ou cumulativamente com pena restritiva de direitos ou quando houve o *sursis*, não podendo, entretanto, incidir sobre recursos indispensáveis ao sustento próprio e da família do condenado, podendo chegar no máximo a um 1/4 da remuneração do condenado e ao mínimo de 1/10 dessa remuneração.

Execução da pena de multa:

Se a multa não for paga voluntariamente ela deve ser executada.

Com a nova redação ao Código Penal pelo Pacote Anticrime acabou a divergência sobre a legitimidade para a cobrança e a competência para julgamento da execução. A multa deve ser executada pelo Ministério público exclusivamente na Vara das Execuções Penais.

Apesar de ser considerada dívida de valor a multa mantém seu caráter de pena. Assim sendo não pode ser cobrada dos sucessores do réu.

Aplicam-se às causas interruptivas e suspensivas da prescrição relacionadas com a lei de Execução Fiscal e Código Tributário Nacional não com o Código Penal.

Não é cabível *habeas corpus* para discutir pena de multa (Súmula 693 do STF)

A correção monetária da multa incide desde a data da infração penal por se tratar de mera atualização de valor.

A execução da multa fica suspensa se sobrevém ao condenado doença mental (art. 52 do CP).

Não é cabível pena isolada de multa nos crimes de violência doméstica contra a mulher.

Permanece válida a Súmula 171 do STJ: *“cominadas cumulativamente em lei especial penas privativa de Liberdade e pecuniária é defeso a substituição da prisão por multa”*.

O art. 60, § 2º prevê a multa substitutiva ou vicariante que pode ser aplicada em substituição a pena privativa de liberdade não superior a 6 meses e desde que presentes os requisitos do artigo 44, II e III do CP.

STJ

1 - *A aplicação da agravante prevista no art. 61, II, "f", do CP, em condenação pelo delito do art. 129, § 9º, do CP, por si só, não configura bis in idem. O tipo penal em sua forma qualificada tutela a violência doméstica, enquanto a redação da agravante, em sua parte final, tutela isoladamente a violência contra a mulher.* (AgRg no REsp 1998980/GO, 10.05.2023)

Atenção: A Terceira Seção acolheu a proposta de afetação dos REsp 2.027.794/MS, 2.026.129/MS e 2.029.515/MS ao rito dos recursos repetitivos, a fim de uniformizar o entendimento a respeito da seguinte controvérsia: "verificar se a aplicação da agravante do art. 61, II, 'f', do Código Penal, em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006), configuraria bis in idem". (TEMA 1197, 25.04.23)

2 - *A Terceira Seção acolheu a proposta de afetação do REsp 2.001.973-RS ao rito dos recursos repetitivos, a fim de uniformizar o entendimento a respeito da seguinte controvérsia: "Definir se eventual confissão do réu, não utilizada para a formação do convencimento do julgador, nem em primeiro nem em segundo grau, autoriza o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal".* (Tema 1194, 25.04.23)

3 – *“A Terceira Seção acolheu a proposta de afetação do REsp 2.031.971/SP ao rito dos recursos repetitivos, a fim de uniformizar o entendimento a respeito da seguinte controvérsia: "Incidência da circunstância agravante prevista no art. 61, II, j, do Código Penal, independentemente de nexos causal entre o estado de calamidade pública e o fato delitivo".* (TEMA 1185, 2023)

4 - *Dosimetria da pena. Atenuante. Confissão qualificada. Pluralidade de qualificadoras. Deslocamento de uma qualificadora para a segunda fase da dosimetria. Agravante. Compensação integral. Possibilidade. Circunstâncias igualmente preponderantes.* AgRg no REsp 2.010.303-MG, 18.11.2022

5 - *A Terceira Seção acolheu a proposta de afetação do REsp 2.003.716/RS, ao rito dos recursos repetitivos, a fim de uniformizar o entendimento a respeito da seguinte controvérsia: definir se é possível a elevação da pena por circunstância agravante, na fração maior que 1/6, utilizando como fundamento unicamente a reincidência específica do réu.* (Tema 1172, 26.10.22)

6 – *Dosimetria da pena. Homicídio qualificado. Concurso de atenuantes e agravantes. Agravante de dissimulação. Atenuante de confissão. Preponderância sobre a dissimulação. Quesitos previstos no art. 67 do CP. Redução da pena.* (HC 557.224, 16.08.22)

7 - Fixação do regime prisional. Circunstância judicial desfavorável. Pena-base acima do mínimo legal. Condenação à pena igual ou inferior a 4 anos de reclusão. Regime inicial aberto. Possibilidade. Dadas as peculiaridades do caso concreto, admite-se que ao réu primário, condenado à pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, seja fixado o regime inicial aberto, ainda que negativada circunstância judicial. (Resp 1.970.578, 03.05.2022)

8 – Cumprimento da pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos substitutiva. Inadimplemento da pena de multa. Compreensão firmada pelo STF na ADI n. 3.150/DF. Manutenção do caráter de sanção criminal da pena de multa. Distinguishing. Impossibilidade de cumprimento da pena pecuniária pelos condenados hipossuficientes. Violação de preceitos fundamentais. Excesso de execução. Extinção da punibilidade. Revisão de tese.

Na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade. **Tema 931.**

9 - A prestação pecuniária prevista no art. 45, §1º, do Código Penal pode ser compensada com o montante fixado com fundamento no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, ante a coincidência de beneficiários. (RESP 1.882.059, 2021)

10 - É inadmissível a fixação de pena substitutiva (art. 44 do CP) como condição especial ao regime aberto. (TEMA 20 e Sumula 493)

11 - O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. (TEMA 190)

Tema: PUNIBILIDADE

1. CONCEITO

É o poder-dever do Estado de **impor** a sanção prevista em lei ou de **executar** a sanção imposta judicialmente.

2. CAUSAS EXTINTIVAS DE PUNIBILIDADE

São causas que extinguem o direito de punir do Estado, ou seja, extinguem o direito de o Estado impor a sanção prevista ou executar a sanção imposta. Desaparece do mundo jurídico apenas o poder punitivo estatal.

Exceções nas quais desaparece a própria infração: **abolitio criminis e anistia**, pois são veiculadas também por lei, assim como a infração penal.

3. EFEITOS DAS CAUSAS EXTINTIVAS DE PUNIBILIDADE

Se a extinção da punibilidade ocorrer **antes do trânsito em julgado** da condenação definitiva, impedirá quaisquer efeitos que decorreriam de uma condenação. Se a extinção da punibilidade ocorrer **após o trânsito em julgado da condenação**, só afastará os efeitos penais principais desta (aplicação de pena ou de medida de segurança); os efeitos penais secundários e os extrapenais permanecerão. Ex. **Sumula 631 do STJ**: o indulto não atinge os efeitos secundários penais e extrapenais.

Exceções: a *abolitio criminis* e a anistia, sejam anteriores ou posteriores à condenação definitiva, apagam todos os efeitos penais (principais e secundários da condenação), permanecendo apenas os extrapenais.

As causas extintivas de punibilidade estão em **rol exemplificativo** do artigo 107 do código penal.

Existem outras causas espalhadas na legislação penal como por exemplo :

- a) Término do período de prova do sursis, do Livramento condicional e da suspensão condicional do processo ;
- b) escusas absolutórias ;
- c) reparação do dano no peculato culposos;
- d) pagamento do tributo ou da contribuição social nos crimes tributários;
- e) anulação do primeiro casamento no crime de bigamia;
- f) Conciliação nos crimes contra a honra (arts. 520 a 522 do CPP);
- g) Cumprimento integral do acordo de leniência ;
- h) cumprimento integral do acordo de não persecução penal.

É possível ainda **causas supraleais** de extinção da punibilidade. Exemplo : súmula 554 do STF .

4. CAUSAS EXTINTIVAS DE PUNIBILIDADE PREVISTAS NO ART. 107 DO CP

a) Morte do agente

O art. 5º, XLV, da CF dispõe que a responsabilidade penal é intransferível (personalíssima – **princípio da personalidade da pena**). Logo, morto o infrator, não há outra solução a não ser a extinção da punibilidade.

O juiz somente pode declarar a extinção da punibilidade pela morte mediante **certidão de óbito original** e após manifestação do Ministério Público (art. 62 do CPP).

Se a **morte ocorrer após o trânsito em julgado** subsistem os efeitos extra penais podendo a sentença ser executada no juízo cível contra os herdeiros .

Sobre extinção da punibilidade com base em **certidão de óbito falsa**, há dois entendimentos:

- 1º) o réu só pode ser processado pela falsidade documental uma vez que não existe revisão criminal em seu desfavor (posicionamento majoritário na doutrina);
- 2º) A sentença fundamentada em certidão de óbito falsa é inexistente e portanto não produz coisa julgada material. além disso o que extingue a possibilidade é a morte e não um documento falso sobre uma morte inexistente (STF/STJ)

b) Anistia, graça e indulto

São institutos pelos quais o Estado, por razões de política criminal, “abre mão” de seu direito de punir.

Podem ser concedidos, inclusive, em ações penais privadas, porque nestas o direito de ação é transferido ao particular, mas o direito de punir permanece sendo do Estado.

Anistia

É concedida por meio de **lei com efeitos retroativos** (lei penal anômala) elaborada pelo Congresso Nacional (arts. 21, XVII, e 48, VIII, da CF).

A anistia extingue a punibilidade de todos os fatos criminosos nela abrangidos, beneficiando, consequentemente, todos os infratores. O STF denomina a anistia “abolitio criminis de efeito temporário e retroativo” (STF, ADI 104/RO, j. 4-6-2007). Tratando-se de lei penal benéfica, a lei da anistia aplica-se retroativamente (art. 2º, parágrafo único, do CP e art. 5º, XLV, da CF); se lei posterior a revogar, não afastará a anistia já concedida.

A competência da união para a concessão da anistia abrange só as infrações penais (STF, ADI 104)

A anistia abrange **fatos** e não **pessoas determinadas**.

Concedida a anistia a extinção da punibilidade é declarada de ofício, a requerimento do MP ou do interessado, por proposta da autoridade administrativa ou do Conselho Penitenciário (art. 187 da LEP)

A anistia pode ser:

1. *própria*: quando concedida antes do trânsito em julgado da condenação;
2. *imprópria*: quando concedida após o trânsito em julgado da condenação;
3. *geral ou plena*: quando concedida sem a exigência de qualquer requisito;
4. *parcial ou restrita*: quando exige o preenchimento de determinados requisitos pelo anistiado (ex.: primariedade);
5. *incondicionada*: quando não exige contraprestação do anistiado; e
6. *condicionada*: quando exige contraprestação do anistiado (ex.: reparação do dano).

A anistia apaga todos os efeitos penais da condenação, permanecendo apenas os civis. Ex.: a sentença condenatória continua sendo título executivo judicial mesmo diante da anistia, podendo ser executada no cível para postulação de indenização contra o infrator ou seus sucessores.

A anistia geralmente é concedida em crimes políticos (anistia especial) e, excepcionalmente, em crimes comuns (anistia comum).

Graça

Aplicada em crimes comuns com **sentença transitada em julgado** e concedida a pessoa determinada (indulto individual). Em regra depende de **provocação da parte interessada**. Na verdade a graça pode ser provocada pelo próprio condenado, pelo MP, pelo Conselho Penitenciário ou pela autoridade administrativa (art. 188 da LEP).

É **ato privativo e discricionário do Presidente da República**, concedidos por decreto presidencial (art. 84, XII, da CF), **delegável** a Ministros de Estado, Procurador-Geral da República e Advogado-Geral da União (art. 84, parágrafo único, da CF). São atos discricionários porque devem obedecer às **vedações constitucionais** a eles.

A graça alcança apenas o **cumprimento da pena permanecendo os efeitos penais secundários e os extrapenais**.

A graça pode ser **plena** quando extingue a pena, ou **parcial** quando acarreta a diminuição ou comutação da pena

A graça pode ser **recusada** no caso de comutação da pena ou se forem impostas condições (CPP, art. 739)

Indulto

O **indulto propriamente dito ou indulto coletivo** pode ser concedido por decreto do Presidente da República para um GRUPO de condenados.

Em regra, exige-se o trânsito em julgado da condenação, embora o STF admita a sua concessão antes desse trânsito (STF, HC 87.801).

Pode ser concedido a condenado que cumpre pena em **quaisquer dos três regimes** prisionais (STJ, REsp 1.828.409).

O juiz da execução deve-se limitar a analisar se o requerente preenche ou não os requisitos previstos no decreto de indulto, não podendo acrescentar novos requisitos ou condições para a extinção da punibilidade, sob pena de constrangimento ilegal (STJ, AgRg no HC 537.982).

Não é possível computar o período de prova do sursis para obtenção do requisito temporal exigido no decreto de indulto (STF, HC 123.698).

O indulto **extingue a pena**, permanecendo os demais efeitos penais e extrapenais não abarcados pelo decreto (Súmula 631 do STJ).

Se o decreto extinguir apenas a pena de prisão, subsiste a de multa (STF, Informativo 884).

O indulto ou graça pode ser:

1. total ou pleno: *extingue a punibilidade;*

2. parcial: *diminui a pena ou autoriza a comutação (substituição) da pena imposta por outra mais branda. Obs.: a comutação ou o indulto parcial, na verdade, **NÃO** extingue a punibilidade, mas apenas atenua a punição;*

3. incondicionado: *não exige contraprestação do beneficiário; e*

4. condicionado: *exige contraprestação do beneficiário.*

Os crimes hediondos e assemelhados (tortura, tráfico e terrorismo) são insuscetíveis de graça, anistia e indulto (art. 5º, XLIII, da CF; art. 2º, I, da Lei n. 8.072/90). O STF já pacificou o entendimento de que é constitucional a proibição do indulto prevista na Lei n. 8.072/90, porque ele nada mais é do que espécie de graça que está expressamente vedada pelo art. 5º, XLIII, da CF. Aliás, se o Decreto Presidencial conceder indulto a condenados por crimes hediondos e assemelhados, será inconstitucional nesse ponto.

O indulto também é **ato privativo e discricionário do presidente da República**, que pode aplicar um instituto a determinados casos e não aplicá-lo a outros por questões de política criminal.

Mas existem **limites** ao presidente da República na concessão do indulto?

No polêmico indulto concedido pelo ex-presidente Michel Temer, o **STF** entendeu **NÃO haver limites** por se tratar de típico ato de governo (ADI 5.874). Na doutrina existe entendimento em sentido contrário de que deve haver limitações constitucionais, inclusive implícitas, aos limites do poder do presidente da República para que o indulto não se transforme em objeto de acordos políticos (Cléber Masson).

A **Súmula 535 do STJ** dispõe que a prática de falta grave não interrompe o prazo para a comutação de pena ou indulto.

É cabível indulto em relação às **medidas de segurança** (STF, RE 628.658).

c) “Abolitio criminis”

Art. 2º do CP: “Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória.”

Então, abolitio criminis é a lei que deixa de considerar um fato ou uma conduta como infração penal. É denominada, pela doutrina, de **causa superveniente de extinção da tipicidade** (apelido doutrinário).

Características da abolitio criminis:

(a) Retroatividade, mesmo que já exista condenação definitiva transitada em julgado e em fase de execução, sendo que, neste último caso, o STF determina que:

Súmula 611 do STF: “Transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao juízo das execuções a aplicação de lei mais benigna.”

(b) Apaga os efeitos **PENAI**S da sentença condenatória (pena, MS, reincidência, maus antecedentes). Entretanto, os demais efeitos (**EXTRAPENAI**S) permanecem (civil/obrigação de reparar o dano/perda do poder familiar) (administrativo/perda do cargo público) (trabalhista /demissão por justa causa).

Obs. aula de aplicação da lei penal trata do tema com maior detalhe

Bloco 5

d) Decadência e perempção

Decadência

A decadência ocorre quando a vítima ou seu representante legal não oferecem, no prazo legal, a representação (nos crimes de ação pública condicionada à representação) ou a queixa (nos crimes de ação penal privada) (art. 103 do CP).

O prazo conta-se da ciência inequívoca da autoria e não de meras suspeitas. Trata-se de prazo preclusivo e ininterrupto, que, portanto, não se suspende, nem se prorroga.

No caso de crime continuado o prazo é contado separadamente para cada delito.

Importante frisar que o prazo de 6 meses é para o oferecimento da representação e da queixa, e não para o recebimento pelo Poder Judiciário.

Decadência	Prescrição
1 – Somente ocorre antes da ação penal ; 2 – Somente ocorre na ação penal pública condicionada à representação e na ação penal privada ; 3 – Extingue o direito de queixa ou de representação e consequentemente o direito de punir 4 – É improrrogável , não se suspende nem se interrompe	1 – Pode ocorrer antes, durante ou após esgotada a ação penal; 2 – Pode ocorrer em qualquer espécie de ação penal ; 3 – Extingue o direito de punir; 4 – É improrrogável mas está sujeita a interrupção e suspensão

e) Perempção

A perempção ocorre nas hipóteses previstas no art. 60 do CPP, quais sejam:

1. Se o querelante deixa de dar andamento ao processo por mais de 30 dias (desde que tenha sido regularmente intimado para praticar o ato processual);
2. Se o querelante falece ou se torna incapaz e não surge um substituto, no prazo de 60 dias, para dar seguimento à ação penal;
3. Se o querelante, injustificadamente, deixa de comparecer a ato processual no qual sua presença é indispensável;
4. Se o querelante não formula o pedido de condenação nas alegações finais (não é necessário pedido expresso de condenação desde que isso possa ser deduzido das alegações)
5. Quando o querelante é pessoa jurídica e se extingue sem deixar sucessor.

A perempção só extingue a punibilidade nos casos de ação penal **exclusivamente privada** e de ação penal **privada personalíssima**. Na ação penal privada subsidiária da pública, se ocorrer qualquer das hipóteses de perempção, o Ministério Público retoma a ação.

A perempção somente se dá durante a ação penal (jamais antes do seu início), e pode ocorrer até o trânsito em julgado da condenação (jamais depois dele). **Só atinge o autor desidioso.**

f) Renúncia e perdão

Renúncia¹

A renúncia ao direito de queixa ocorre sempre **ANTES** do início da ação penal privada. É **ato unilateral** da vítima, que **NÃO** depende de aceitação do infrator .

Somente pode ocorrer na **ação privada propriamente dita** e **NÃO** na ação privada subsidiária da pública .

A renúncia pode ser expressa ou tácita (prática de ato incompatível com a vontade de processar o infrator – art. 104 do CP).

O recebimento de indenização **NÃO** significa renúncia tácita ao direito de queixa (**salvo** na Lei n. 9.099/95). Na Lei n. 9.099/95 a composição civil de danos (recebimento de indenização pelos danos sofridos com o crime) acarreta renúncia ao direito de queixa (art. 74).

A renúncia em relação a um dos infratores a todos se estende, o que significa dizer que a vítima deve processar todos os infratores ou **NÃO** poderá processar nenhum deles. Por outro lado, a renúncia por parte de uma das vítimas **NÃO** impede o direito de queixa das outras.

¹ **Art. 104 do CP:** “O direito de queixa não pode ser exercido quando renunciado expressa ou tacitamente.

Parágrafo único - Importa renúncia tácita ao direito de queixa a prática de ato incompatível com a vontade de exercê-lo; não a implica, todavia, o fato de receber o ofendido a indenização do dano causado pelo crime.”

Perdão² (do ofendido)

O perdão somente extingue a punibilidade na **ação exclusivamente privada** e na **ação privada personalíssima**, jamais na ação privada subsidiária da pública, e somente pode ocorrer **DURANTE A AÇÃO PENAL** (art. 104, caput, do CP). Somente tem cabimento até o trânsito em julgado da condenação (art. 106, § 2º, do CP).

O perdão pode ser expresso ou tácito (ato incompatível com a vontade de prosseguir na ação – art. 106, § 1º, do CP) e pode ser processual (concedido no processo) ou extraprocessual (concedido fora do processo).

O perdão é ato bilateral, pois só produz efeitos se aceito pelo querelado (acusado). Se este recusar o perdão, o processo prosseguirá (art. 106, III, do CP). O perdão pode ser aceito expressa ou tacitamente (se o querelado não se manifesta sobre o oferecimento do perdão, presume-se que o aceitou).

O perdão oferecido a um dos querelados é válido para todos, mas só produz efeitos em relação ao acusado que o aceitar (art. 106, I, do CP). Por outro lado, o perdão concedido por um dos querelantes não prejudica o direito dos demais de prosseguirem na ação (art. 106, II, do CP).

g) Retratação

Retratar-se significa desmentir o que foi dito, desdizer-se. No CP a retratação está prevista como causa extintiva de punibilidade para os seguintes crimes:

Calúnia e difamação (arts. 139 e 140 do CP)	Falso testemunho e falsa perícia (art. 342 do CP)
1. A retratação deve ocorrer no mesmo processo que apura tais crimes e antes da sentença. 2. Não beneficia os demais acusados (extingue a punibilidade apenas do acusado que fez a retratação).	1. A retratação deve ocorrer no mesmo processo no qual ocorreu a men tira. 2. Beneficia todos os demais acusados (extingue a punibilidade de todos os infratores).

Obs. leia-se 138 e 139 do CP

h) Perdão judicial

O perdão judicial somente pode ser aplicado nos **casos expressos em lei**. Ex.: arts. 121, § 5º, e 129, § 8º, do CP. É cabível tanto para **crimes dolosos** quanto para **crimes culposos**.

² Art. 106 do CP: “O perdão, no processo ou fora dele, expresso ou tácito:

I - se concedido a qualquer dos querelados, a todos aproveita;

II - se concedido por um dos ofendidos, não prejudica o direito dos outros;

III - se o querelado o recusa, não produz efeito.

§ 1º - Perdão tácito é o que resulta da prática de ato incompatível com a vontade de prosseguir na ação.

§ 2º - Não é admissível o perdão depois que passa em julgado a sentença condenatória.”

A jurisprudência admite o perdão judicial de forma ampla, quando o crime atinge parentes, cônjuge, noivo, amigos etc. do infrator.

No caso de concurso de crimes o perdão judicial NÃO pode ser aplicado automaticamente a todos eles mas apenas ao delito no qual ficar comprovado o vínculo familiar ou de amizade que justifique a extinção da punibilidade (STJ, Resp 1.444.699).

Para o STJ, a sentença que concede o perdão judicial NÃO é nem condenatória nem absolutória, mas declaratória de extinção da punibilidade (Súmula 18 do STJ). De qualquer forma, por expressa previsão legal, a sentença que concede o perdão judicial NÃO gera reincidência (art. 120 do CP).

Diferentemente do perdão do ofendido, que é ato bilateral (só produz efeito se for aceito pelo acusado), o perdão judicial é **ato unilateral**, porque produz efeito independentemente da vontade do réu.

O perdão judicial é **causa pessoal ou subjetiva de extinção de punibilidade** e, por isso, NÃO se transfere aos demais corréus.

A doutrina discute se o perdão judicial pode ser **concedido antes da sentença final**. Há autores que sustentam que o perdão judicial, sendo causa extintiva de punibilidade, pode ser concedido a qualquer tempo, nos termos do art. 61 do CPP. Outros, ao contrário, entendem que o perdão judicial pressupõe a prática de fato típico, ilícito e culpável, o que pressupõe a apuração em instrução criminal. Logo, só pode ser concedido ao final do processo, na sentença (Cléber Masson).

Visualize uma síntese das sete primeiras causas extintivas da punibilidade:

Morte	An./Gr./Indulto Anistia se refere a <u>fatos</u> . Extingue os efeitos penais. Concedida antes/depois TJ da sentença. Graça se destina a <u>pessoa</u> determinada. Extingue/diminui/comuta a pena. Concedida depois TJ da sentença. Indulto se destina a um <u>grupo</u> . Extingue/diminui/comuta a pena. Concedido, em regra, depois do TJ da sentença. Mas, STF, entende que antes/depois do TJ da sentença.	Abolitio Retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso.	Dec./Perempção Decadência .APPCondicionada .APPPrivada Perempção .APExclus.privada .APPri.personalíss	Re./Perdão OFEND. Renúncia <u>Antes</u> da: .APri.propri. dita Perdão O (bilateral) <u>Durante</u> as: .APEx.privada .APPri.personalíss	Retratação <u>Dentro</u> do processo de calúnia/difamação . <u>Dentro</u> do processo que foi proferida a mentira do perito/testemunha .	Perdão JUDICIAL -crimes culposos dolosos -UNILATERAL -concedido (1ª corrente) <u>antes</u> da sentença (2ª corrente) <u>na sentença</u> . -NÃO SE COMUNICA
-------	--	---	---	--	--	--

Agora a causa extintiva da punibilidade que merece especial atenção:

i) PRESCRIÇÃO

1. CONCEITO

É a perda do poder-dever do Estado de aplicar a **sanção** prevista ou de executar a pena imposta, em razão do decurso do tempo. A prescrição impõe um limite temporal ao poder-dever de punir do Estado.

Por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser reconhecida em qualquer tempo (art. 61 do CPP)³, até mesmo depois de transitar em julgado a condenação, inclusive pela via do habeas corpus.

Fundamentos: a) Segurança jurídica para o infrator ; b) mecanismo contra ineficiência do Estado; c) inconveniência da sanção penal.

2. NATUREZA JURÍDICA DAS NORMAS QUE VERSAM SOBRE PRESCRIÇÃO

As normas que tratam da prescrição são normas penais (de direito material), portanto, se submetem à regra do art. 5º, XL, da CF⁴: quando são mais benéficas ao infrator, retroagem, e quando são prejudiciais não retroagem.

É matéria prejudicial ao exame de mérito por constituir fato impeditivo do direito estatal de punir (STJ, Rcl 4515).

3. IMPRESCRITIBILIDADE

Em regra, todos os crimes, por mais graves que sejam, estão sujeitos à prescrição. Mas a CF (art. 5º, XLII e XLIV) prevê, excepcionalmente, dois crimes imprescritíveis: **racismo** (previsto na Lei n. 7.716/89) e **ação de grupos armados civis e militares contra o Estado Democrático de Direito e a Ordem Constitucional** (prevista na Lei n. 7.170/83). **Atenção:** A Lei 14.197/21 revogou expressamente a Lei 7.170/83 (LSN), sepultou a conduta contravencional de associação secreta, e por último acrescentou o novo título ao Código Penal com a rubrica de crimes contra o Estado Democrático de Direito.⁵Obs.:

1. O crime de **injúria racial ou preconceituosa** do art. 140, § 3º do CP é espécie do gênero racismo, portanto, imprescritível – **STF HC 154.248**. □ Hoje, é tratada como racismo e está na lei 7.716/89

2. Os crimes sujeitos à jurisdição do **Tribunal Penal Internacional são imprescritíveis** (art. 29 do Estatuto de Roma do TPI, promulgado no Brasil pelo Decreto n. 4.338/2002). Por outro lado, o **STF decidiu na ADPF 153** que o Brasil não assinou a Convenção Sobre a Imprescritibilidade dos Crimes de Guerra e dos Crimes contra a Humanidade razão pela qual eles prescrevem.

³ Art. 61 do CPP: “Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.

Parágrafo único. No caso de requerimento do Ministério Público, do querelante ou do réu, o juiz mandará autuá-lo em apartado, ouvirá a parte contrária e, se o julgar conveniente, concederá o prazo de cinco dias para a prova, proferindo a decisão dentro de cinco dias ou reservando-se para apreciar a matéria na sentença final.”

⁴ Art. 5º, XL, da CF: “a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu.”

⁵ A nova lei acrescenta um novo título ao CP com capítulos que tratam de crimes contra a soberania nacional, as instituições democráticas, o funcionamento das instituições democráticas no processo eleitoral, o funcionamento dos serviços essenciais e a cidadania, além de um capítulo com as disposições comuns a eles. O projeto também revoga artigo da Lei das Contravenções Penais que trata dos crimes referentes à paz pública. De acordo com esse dispositivo, participar de associação periódica de mais de cinco pessoas “sob compromisso de ocultar à autoridade a existência, objetivo, organização ou administração da associação” — ou seja, em segredo — **acarretava** prisão de até 6 meses ou multa.

Prevalece na doutrina o entendimento de que as hipóteses de imprescritibilidade previstas na CF são taxativas, NÃO podendo o legislador ordinário ampliá-las. A prescrição constitui direito fundamental (direito fundamental de 1ª geração; liberdade pública negativa).

3. Distinção entre Prescrição e Decadência:

Decadência	Prescrição
1- Somente ocorre antes da ação penal;	1- Pode ocorrer antes, durante, ou após esgotada a ação penal;
2- Somente ocorre na ação penal pública condicionada à representação e na ação penal privada;	2- Pode ocorrer em qualquer espécie de ação penal;
3- Extingue o direito de queixa ou de representação, e consequentemente o direito de punir	3- Extingue o direito de punir;
4- É improrrogável, NÃO se suspende nem se interrompe	4- É improrrogável mas está sujeita à interrupção e suspensão

4. ESPÉCIES DE PRESCRIÇÃO:

PPP	PPE
a) Ocorre antes do trânsito em julgado para ambas as partes, sendo que, na PPP intercorrente e na PPP retroativa, existe trânsito em julgado apenas para a acusação. SUBDIVIDE-SE: 1 – PPP propriamente dita (prescrição da ação penal ou prescrição em abstrato): calculada com base na pena máxima prevista; PPPPD 2 – PPP intercorrente: calculada com base na pena aplicada; PPPI 3 – PPP retroativa: calculada com base na pena aplicada. PPPR	a) Ocorre após o trânsito em julgado para ambas as partes
b) Impede todos os efeitos penais e extrapenais da condenação	b) Impede somente a imposição da pena e da medida de segurança. Os demais efeitos penais e extra penais permanecem.

Obs. medida de segurança prescreve

4.1. EFEITOS

A PPP impede **todos** os efeitos da sentença condenatória penais e extrapenais principais ou secundários.

A PPP impede o início ou o prosseguimento da ação penal. Se a ação penal ainda não foi instaurada, deve o inquérito ser arquivado. Se for oferecida denúncia ou queixa, deve ser rejeitada. Se a ação estiver em andamento, deve o juiz declarar a extinção da punibilidade e extinguir o processo sem julgamento do mérito.

A PPE **somente** impede a execução da pena ou MS (extingue somente a execução, subsistindo a condenação). Todos os demais efeitos penais e extrapenais da condenação subsistem.